

1005823-76.2022.8.26.0224

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Base de Cálculo

Magistrado: Caroline Quadros Da Silveira Pereira

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... é imposto sobre contratos ou sobre o tráfico jurídico), mas grava as operações de circulação de mercadorias, no caso a circulação da energia, sendo que se encontra na legislação federal, como exaustivamente comprovado, a eleição do momento de ocorrência do fato gerador saída da energia elétrica das linhas de transmissão da concessionária e entrada no estabelecimento do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara da Fazenda Pública

Rua Dos Crisântemos, 29, 17º andar, Guarulhos - SP - cep 07091-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1005823-76.2022.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1005823-76.2022.8.26.0224

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Base de Cálculo

Requerente:

Metalic Acessórios para Laboratório Ltda Epp

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Caroline Quadros Da Silveira Pereira

Vistos.

Trata-se de ação declaratória c.c repetição de indébito proposta por METALIC ACESSÓRIOS PARA LABORATÓRIO LTDA EPP em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Alegou o autor que é consumidor final de energia elétrica fornecida pela concessionária local EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, com o número de instalação, nº150735953. Informou que a presente ação versa sobre a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre o autor e o Fisco Estadual, no que tange à incidência do ICMS. Disse que possui contrato perante a concessionária EDP na modalidade A4 Verde Livre – Industrial e contrata demanda de potência ativa (energia) de 100KW fora da ponta. Esclareceu que se comprometeu contratualmente ao pagamento da demanda contratada, bem como ao adimplemento do eventual consumo de energia elétrica utilizada que porventura ultrapasse o potencial contratado. Entretanto, disse que a simples contratação de “demanda de potência” não pode ser fato gerador para sua incidência e muito menos o valor total do respectivo contrato servir como base de cálculo, conforme entendimento da súmula 391 do STJ, referente à incidência do ICMS. Informou que a referida súmula consolidou duas premissas,

quais sejam, que para fins de incidência do ICMS, a energia elétrica é considerada mercadoria e não serviço, bem como o efetivo consumo representa a sua circulação e, conseqüentemente, autoriza a tributação pelo ICMS e não apenas a disponibilização. Reverberou acerca da matéria de repercussão geral nº 593.824 e afirmou que a demanda de potência não se sujeita, nem parcialmente, ao ICMS porque não configura uma operação de consumo de energia. Todavia, informou que o Estado de São Paulo está exigindo o tributo sobre base de cálculo superior àquela legal e constitucionalmente prevista sem observar a decisão em sede de Repercussão Geral no julgamento do Tema 176 do STF, motivo pelo qual o autor pugnou pela declaração da inexistência de relação jurídico-tributária que o obrigue a recolher o ICMS sobre toda a demanda de potência contratada, devendo ser restringida a base de cálculo para o efetivo consumo de energia elétrica. Alegou que possui legitimidade para figurar no pólo ativo, uma vez que é efetivamente quem paga o imposto incidente sobre o consumo de energia elétrica. Ademais, asseverou que o fato gerador do imposto estadual ocorre no momento da efetiva entrega da energia elétrica ao consumidor, que se perfaz pelo consumo da energia no seu estabelecimento e portanto a mera colocação à disposição do consumidor de determinada quota de potência (reserva de demanda) não configura o fato gerador do ICMS. Asseverou que o legislador estadual, na lei nº 6.374/1989, elegeu nessa modalidade de incidência do ICMS, o momento da saída da energia elétrica do estabelecimento gerador para demarcar a incidência da norma jurídico tributária, sendo esse o critério temporal de incidência do ICMS e portanto exigir o ICMS sobre uma demanda que foi apenas disponibilizada, é fazer incidir o tributo sobre fato gerador não previsto pela legislação. Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão de exigibilidade do crédito tributário referente à exclusão da demanda contratada da base de cálculo do ICMS devido nas operações com energia elétrica (consumo) do Autor e no caso de concessão em cumprimento à decisão a ser proferida, discrimine, nas próprias faturas de consumo, o respectivo montante. Requereu a procedência da ação para que seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre o Autor e a Fazenda Pública do Estado, reconhecendo o direito à exclusão da DEMANDA CONTRATADA da base de cálculo do ICMS devido nas operações com energia elétrica, bem como seja ao final determinado à Concessionária Distribuidora a exclusão dos respectivos valores das faturas de energia elétrica futuras, tudo a partir da data da propositura da ação e a restituição ou compensação (conforme critério do Autor) dos valores indevidamente recolhidos correspondentes à inclusão da demanda contratada na base de cálculo do ICMS devido nas operações com energia elétrica dos últimos 05 anos anteriores à propositura da ação, bem como dos valores recolhidos durante o trâmite da ação, acrescidos da taxa selic a contar da data do recolhimento indevido (fls. 1/19). Juntou documentos (fls. 20/52). Determinada a redistribuição livre (fl. 53). Determinada a parte autora emendar a inicial no prazo de 15 dias sob pena de indeferimento da inicial (fl. 56). A parte autora emendou a inicial (fls. 59/66), indicando endereço eletrônico, requerendo que conste nos pedidos letra "a", "c" e "d" o número da unidade consumidora nº150735953. Quanto ao valor da causa, informou que apenas poderá ser feito o pedido líquido e certo quando a parte ré apresentar as 60 últimas faturas, não sendo possível produzir pela parte autora vez que a Concessionária de Energia não disponibiliza em seu site, sendo impossível o Autor atribuir valor certo à causa, uma vez que um dos pedidos é exatamente no sentido de que a ré apresente os documentos necessários para viabilizar o cálculo do pretendo indébito, o que, certamente, deverá ser feito em fase de liquidação. Requereu juntada de nova procuração, bem como, que seja identificado o número da unidade consumidora, nº 150735953. Pugnou pelo reconhecimento do valor da causa R\$ 10.000,00 reais. Por fim, reiterou o pedido de tutela antecipada. Juntou documentos (fl. 67/80). Em decisão, recebida a emenda à inicial e foi concedida a tutela provisória de urgência à parte autora, para determinar a suspensão das cobranças indevidas, decorrentes da inclusão da demanda contratada, devendo essa ser excluída da base de cálculo do imposto ICMS das contas de energia elétrica da autora, sendo a instalação de número 150735953 (fls. 81/83).

A parte autora peticionou, requerendo a expedição de Ofício para que a concessionária ré EDP, cumpra a r. decisão proferida, discrimine, nas próprias faturas de consumo, o respectivo montante correspondente a Exclusão do ICMS sobre a DEMANDA CONTRATADA, nos termos da decisão de fls. 81/83 (fl. 92), que restou indeferido o pedido, vez que cabe à parte ré cessar a cobrança do ICMS (fl. 93). A FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contestou o feito (fls. 100/120), alegando, preliminarmente, quanto a ilegitimidade das substituídas no pedido de devolução dos valores pagos em face do art. 166 do CTN, vez que a pretensão da parte autora revela a carência da presente ação, em vista da absoluta ausência de interesse processual e legitimidade "ad causam" para sua propositura, pois, por se tratar de contribuinte que possui consumidor, tem-se que o custo da energia elétrica foi incorporado ao preço das mercadorias e serviços oferecidos, não tendo as mesmas arcado com o ônus econômico da cobrança do tributo, suportado este pelo adquirente de suas mercadorias e serviços, isto é, o consumidor. Ademais, o tributo indireto, àquele que arca com o valor do imposto cabe a propositura das ações tendentes a resguardar o seu interesse econômico, nos termos do que determina o artigo 166 do CTN, cabendo a parte autora provar que não foi repassado o custo da energia elétrica para terceiros ou, se o ônus foi de fato suportado por elas, não podendo procurar restituição daquilo que não foi suportado de fato. No mérito, sustentou sobre a demanda reservada de energia elétrica e legitimidade da incidência e da composição da base de cálculos, explicando que "demanda contratada" não equivale, como equivocadamente supõe a exordial, a uma sobra ou reserva de energia elétrica não consumida, mas sim, que não é grandeza de consumo de energia, mas é medida de potência, reforçando que os sistemas elétricos são dimensionados pela demanda, e não pelo consumo de energia. Aduziu que a pretensão autoral consiste, no âmago e em suma, a uma restrição da competência tributária reservada ao Estado de São Paulo pelo artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, norma constitucional que assegura ao Estado o direito de tributar as operações relativas à circulação de mercadorias, dentre as quais se insere o fornecimento de energia elétrica, e que a autora paga por isso em decorrência de contrato de "demanda contratada", através do qual garante que o sistema de geração, transferência e distribuição de energia ostente a potência necessária para assegurar, sem sobressaltos, ao atendimento não apenas de sua média de consumo, mas também de seus picos de consumo, tanto que o valor da operação de fornecimento de energia elétrica contempla não apenas o valor da energia consumida, mas também o valor da potência disponibilizada, que é um custo da operação, sendo que o ICMS incide, assim, sobre o valor total da nota fiscal/fatura emitida pela concessionária e que contém o valor cobrado do consumidor, ausente qualquer razão plausível, para prestigiar o errôneo entendimento da Autora. Arguiu sobre o posicionamento do STJ acerca da demanda de potência e tema 176 do STF, logo, a parte autora, ao firmar contrato de "demanda contratada", não está desperdiçando energia ou adquirindo excedentes, como erroneamente supõe o particular. Asseverou em caso de entendimento diverso, quanto a decadência e a prescrição quinquenal, para quem em caso de condenação desta corrê, para que a repetição de indébito alcance apenas o prazo de cinco anos. Asseverou que ao autor compete o ônus probatório, a qual deixou de colacionar aos autos documentos para comprovar suas alegações. Arguiu quanto aos juros e da atualização monetária, pleiteia para que seja aplicado os índices do IPCA-E para fins de correção monetária, do desembolso até o trânsito em julgado e somente após o trânsito em julgado é que seria cabível aplicar-se a taxa Selic (exclusivamente, pois a mesma já contempla juros e correção monetária). Requereu a improcedência dos pedidos da exordial, extinguindo o processo com resolução do mérito, condenando a parte autora ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios. Determinado as partes manifestarem acerca do interesse na produção de provas (fl. 121).

A ré informou não possuir mais provas a produzir, entretanto requereu que fosse intimada para acompanhar as provas requeridas pela postulante (fl. 123).

Houve réplica, alegando preliminarmente, ser inadmissível a arguição de suspensão do presente feito, haja vista que o julgamento do TEMA 176 do STF não é passível de recursos. Alegou que muito embora não seja sujeito passivo do ICMS é efetivamente

quem paga o imposto incidente sobre o consumo de energia elétrica, motivo pelo qual faz jus em figurar no polo ativo da demanda. Asseverou que é contribuinte indireto do ICMS incidente sobre a energia elétrica, motivo pelo qual não consegue realizar a prova de que repassa o ICMS aos adquirentes das mercadorias. Por fim, alegou que não deve haver incidência do ICMS sobre a Demanda de Potência Reservada/Contratada. Requereu a total procedência da ação (fls. 127/134).

O autor informou não ter mais provas a produzir e, portanto, requereu o julgamento antecipado da lide (fl. 135).

É o relatório

Fundamento e decido

O feito comporta julgamento antecipado, pois os fatos estão provados documentalment, sendo desnecessária a produção de provas em audiência ou técnica, nos termos do art. 355, I do CPC.

De início, afasto a arguição de ilegitimidade ativa.

Conforme entendimento pacificado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, os consumidores e contribuintes de fato do ICMS sobre a demanda contratada e não consumida detém legitimidade ativa para propor a demanda:

APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA E NÃO UTILIZADA. 1. Preliminar de ilegitimidade ativa. Descabimento. Admissibilidade de propositura da ação pelo consumidor final. Questão pacificada pelo C. STJ por meio do julgamento do REsp nº 1.299.303/SC, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos. 2. Pretensão de afastar a cobrança de ICMS sobre a "demanda reservada de potência", bem como restituir ou compensar os valores pagos a maior. Cabimento. Não pode incidir o ICMS sobre a demanda de energia elétrica reservada e não consumida, já que somente ocorre a circulação se a energia tiver sido efetivamente entregue e consumida. Precedentes do C. STJ e desta E. Corte. Entendimento sedimentado pela Súmula nº 391 do STJ. Possibilidade de repetição de indébito. Valores apurados em liquidação de sentença. Aplicação da taxa SELIC no que tange à atualização monetária e juros de mora. Sentença reformada. Recurso provido (TJSP; Apelação Cível 0029266-87.2011.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/03/2018; Data de Registro: 28/03/2018) (grifo próprio)

No mérito, a ação é procedente.

É controversa a legalidade ou não da tributação do ICMS sobre a demanda de energia contratada, tendo a ação por objeto o contrato firmado entre as partes, conforme contas de consumo às fls. 32/44 e 68/80, dos autos.

Dispõe a Lei Complementar 87/1996, que em seu artigo 12, inciso I: Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte.

No caso da energia elétrica, considerada mercadoria pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 155, §3º, a circulação ficcional ocorre mediante o seu consumo, ou seja, com a efetiva saída da energia elétrica do sistema da concessionária de energia e seu ingresso no estabelecimento do consumidor.

Com efeito, o fato gerador do ICMS dá-se no momento do consumo efetivo da energia, equiparada à mercadoria para fins de incidência do tributo.

Apenas com o consumo efetivo de energia surge a obrigação tributária, sendo este a base de cálculo do ICMS.

Logo, deve se entender que a demanda contratada pela parte autora não pode ser considerada consumo efetivo de energia elétrica, observando-se que a primeira tem relação com a reserva de potência contratada a qual é medida por Kw (quilowatt), enquanto a segunda diz respeito à quantidade de energia elétrica consumida que é medida por Kwh (quilowatt-hora), ou seja, deve ser excluído do cálculo do ICMS o valor da demanda reservada de potência quando não houver o respectivo fornecimento. Assim entendeu o Min. José Delgado no julgamento do Recurso Especial nº 222810/MG do C. STJ, em seu voto vencedor: "O ICMS incide sobre o valor da energia elétrica que tenha sido concretamente consumida pela empresa, em virtude de que somente essa quantidade é que deve ser considerada como utilizada... Assim, como são nítidas in casu dois valores correspondentes a duas situações fáticas distintas (numa,

fornecimento de energia, noutra, garantia de potência), e uma destas situações não chega a configurar o fato gerador do ICMS, somente caberá falar da incidência do imposto sobre o valor da operação de que resultou a entrega de energia e não daquela que resultou mera garantia de potência.... Ora, o ICMS não grava o negócio jurídico da compra e venda (não é imposto sobre contratos ou sobre o tráfico jurídico), mas grava as operações de circulação de mercadorias, no caso a circulação da energia, sendo que se encontra na legislação federal, como exaustivamente comprovado, a eleição do momento de ocorrência do fato gerador saída da energia elétrica das linhas de transmissão da concessionária e entrada no estabelecimento do consumidor."

No mesmo sentido a jurisprudência do E. TJSP:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. ICMS. Energia elétrica. Reserva de demanda. Incidência restrita à energia elétrica efetivamente consumida. Repetição de valores cobrados e recolhidos a mais. Sem incidência de ICMS sobre energia elétrica não consumida porque não transferida para o consumidor. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 391, e Supremo Tribunal Federal, RE 593824, Tema 176. Diferenças entre as demandas de potência contratada e a efetivamente utilizada comprovadas pelas contas de energia de elétrica. Recomposição dos valores cobrados e recolhidos a mais desde cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com correção monetária pelo IPCA-E, de cada recolhimento até a data de trânsito em julgado, e após pela taxa SELIC, que engloba correção e juros de mora. Demanda procedente. Recurso do Estado não provido, parcialmente provido o reexame necessário, quanto à correção monetária e juros de mora. (TJSP; Apelação Cível 1007164-77.2021.8.26.0320; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/05/2022; Data de Registro: 24/05/2022) (grifo próprio)

EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO ICMS. INCIDÊNCIA. CONTRATO DE RESERVA DE DEMANDA OU POTÊNCIA ELÉTRICA. V. acórdão proferido em 17.08.2011. Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.040, inciso II do CPC/2015). Necessidade de adequação do v. acórdão proferido por esta C. 13ª Câmara de Direito Público, nos termos do entendimento pacificado pela Suprema Corte no julgamento do RE nº 593.824/SC, Tema nº 176, E. STF, DJe 19.05.2020.

ILEGITIMIDADE ATIVA. Inocorrência. Entendimento pacificado pelo C. STJ, REsp nº 1.299.303/SC (tema 537), no sentido de que o contribuinte de fato tem legitimidade ativa para ajuizar demanda relativa ao ICMS incidente sobre energia elétrica. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. A base de cálculo do tributo é o valor da tarifa apurada com base na potência efetivamente utilizada. Inclusão dos valores referentes à mera disponibilização de potência. Impossibilidade. Precedentes desta Corte. Aplicação da Súmula 391 do STJ e do Tema 176 do STF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. Restituição do tributo pago a maior a título de ICMS, cuja determinação expressa na r. sentença para que seja respeitada a prescrição quinquenal. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Tratando-se de restituição de tributo, deve-se aplicar a taxa SELIC no que diz respeito aos juros de mora e atualização monetária, incidentes a partir do trânsito em julgado da decisão. Inteligência do art. 167 § único do CTN e da Súmula 188 do E. STJ. (TJSP; Apelação Cível 9076862-15.2007.8.26.0000; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022) (grifo próprio)

RECURSOS REPETITIVOS - Julgamento do REsp. nº 947.206-RJ pelo STJ (tema nº 229) - Art. 1.030, II, do novo CPC - Ação de repetição de indébito tributário - ICMS incidente sobre demanda contratada de energia elétrica - Acórdão reconhecendo que o imposto deve incidir somente sobre a energia consumida, afastando a prescrição quinquenal - Impossibilidade - Pretensão de reembolso que deve ser ajuizada dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 168, I, CTN - Precedentes - Adequação do julgamento anterior. (TJSP; Apelação Cível 0127766-66.2005.8.26.0000; Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13.VARA; Data do Julgamento:

02/05/2022; Data de Registro: 02/05/2022)(grifo próprio)

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação tributária c/c repetição de indébito c. Pretensão de exclusão da cobrança de ICMS sobre valores referentes à demanda de potência. Sentença de procedência, para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária entre as partes que obrigue à inclusão, na base de cálculo do ICMS, do montante equivalente à demanda de energia elétrica contratada e não consumida pela consumidora, bem como para condenar a Fazenda Pública no pagamento do valor recolhido a maior, respeitada a prescrição quinquenal. A demanda de potência elétrica não é passível, por si, de tributação via ICMS. Portanto, a disponibilização de potência elétrica no ponto de entrega (pela distribuidora ao consumidor) não constitui fato gerador do ICMS, o qual possui como pressuposto indispensável o consumo da energia, sem a qual não há circulação. Entendimento firmado pelo C. STF na tese de repercussão geral, Tema 176: "A demanda de potência elétrica não é passível, por si só de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor". Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000009-92.2017.8.26.0601; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Socorro - 1ª Vara; Data do Julgamento: 29/04/2022; Data de Registro: 29/04/2022) (grifo próprio)

REEXAME NECESSÁRIO - Tributário - ICMS - Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária - Contrato de Compra de Energia Regulada (CCER) - Incidência do tributo sobre a totalidade da demanda de energia elétrica contratada - Pretensão da autora de que a base de cálculo do ICMS se limite apenas à energia elétrica efetivamente consumida - Sentença que julgou procedente o pedido com integral fundamento no Tema 176, do STF e na Súmula 391, do STJ, com determinação de remessa necessária - Não cabimento - Inteligência do art. 496, §4º, incisos I e II, do Código de Processo Civil - Precedentes desta C. Corte e Câmara - Reexame necessário não conhecido. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1021276-80.2020.8.26.0451; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2022; Data de Registro: 17/02/2022)(grifo próprio)

Esse mesmo entendimento consta no verbete da Súmula 394 do STJ, segundo a qual o ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada, bem como aqueles posado na Súmula 391 do STJ: "O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada. "

Quanto ao pleito de repetição de indébito, vale citar o disposto na súmula 546 do STF, in verbis: "Cabe a restituição do tributo pago indevidamente, quando reconhecido por decisão, que o contribuinte de jure não recuperou do contribuinte de facto o quantum respectivo."

Se a incidência do imposto se deu sobre base de cálculo ora considerada ilegal, é de rigor o ressarcimento ao contribuinte, respeitada a prescrição quinquenal. Quanto aos valores a serem ressarcidos, o montante será melhor apurado em liquidação de sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar a inexistência de relação jurídico tributária entre as partes para fins de não incidência do ICMS sobre a energia de potência contratada e não utilizada, definindo-se a base de cálculo do referido tributo unicamente sobre a energia elétrica efetivamente consumida e repetir à autora os valores de ICMS pagos sobre a "demanda contratada" não consumida pela unidade consumidora (instalação nº 150735953), nos últimos cinco anos, a ser apurada em liquidação de sentença, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora desde a data de cada recolhimento até a data do pagamento.

A atualização monetária deverá observar a tese fixada pelo STF, no julgamento do RE 870947: "O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se

inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina", aplicando-se como índice o IPCA-E, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.

Os juros moratórios deverão ser calculados com base no índice da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 30/06/2009 (STF/RE 870947 – Tema 810).

Arcará a ré, sucumbente, com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, contando-se juros de mora de um por cento ao mês a partir do trânsito em julgado. Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido pelos litigantes, com os registros devidos, independentemente de nova conclusão, arquivem-se os autos, com as cautelas legais, observadas as NSCGJ/SP.

P.I.

Guarulhos, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA